

1500633-74.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se que não há apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciar terem os acusados praticado o tráfico ilícito, com auxílio mútuo.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500633-74.2021.8.26.0559 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500633-74.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAMON BARBOSA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

RAMON BARBOSA DA SILVA e FRANCISCO RÉGIS BARBOSA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal.

Consta que no dia 30 de abril de 2021, por volta das 20h30min, na Avenida Miguel Lucio de Lima, 1.148, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos, guardavam e mantinham em depósito, os réus, para futura entrega a terceiros, cento e setenta e cinco porções de cocaína na forma de "crack", pesando 88,4g, substância esta entorpecente e determinante de dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Portavam, ainda, os acusados, R\$ 335,00.

Continua a inicial no sentido de terem os réus se associado para o fim de praticar,

reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Policiais militares, após informações da genitora dos réus sobre a prática do comércio ilícito pelos filhos, no imóvel da família, efetivaram diligências no local, onde abordaram os acusados, localizando-se, nas vestes de ambos, o dinheiro, bem como, na cozinha, as porções individualizadas do entorpecente.

Oferecida a denúncia foram os acusados notificados e apresentaram defesa prévia.

Recebida a denúncia foram os réus citados e se designou audiência de instrução, na qual foram ouvidas três testemunhas comuns e uma apontada pela defesa.

Após, foram interrogados os réus.

Em debate, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria dos delitos, requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição dos réus alegando, em suma, serem insuficientes as provas colhidas a delinear os crimes.

É o relatório.

DECIDO.

Por óbvio, inexistente violação ilícita do domicílio, pois, conforme narrado pelos policiais, sob o crivo do contraditório, o ingresso nas residências decorreu, por primeiro, ante estado de flagrância, constatado pelo encontro das porções dos entorpecentes no local, e ao depois, ante autorização, da genitora dos réus, os quais, inclusive, acompanharam toda a diligência de busca, no imóvel.

Em se tratando de delito de tráfico de drogas, enquanto o agente possuir substâncias tóxicas, poderá ser preso em flagrante, tratando-se, pois, de crime permanente, propiciando a violabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.

Assim, em razão do estado de flagrância dos denunciados, excepcionada está a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, devendo ser, portanto, afastada a alegação de irregularidade da diligência policial.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FRANQUEADO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (art. 33 da Lei nº 11.343/06). 2. O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garante ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC n. 306.560/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015). 3. Uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade (HC n. 310.338/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 18/5/2015). 4. Para rever a conclusão da instância de origem, quanto à ausência de autorização para a entrada no domicílio, seria indispensável a revisão do conjunto fático-probatório, providência que não encontra espaço em recurso especial, em razão da vedação da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido." (STJ, REsp 1.909.082-AgRg/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 02.02.2021).

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão acostado às fls. 23/24, que aponta o encontro do tóxico e do dinheiro em tela.

Ainda, no pertinente à materialidade, há o laudo de constatação de fls. 73/74 e o laudo de exame químico toxicológico de fls. 126/128, concludentes no sentido de se tratar de cocaína a substância encontrada.

A mídia contendo gravação das imagens de "Francisca Regina Estevão", genitora dos réus, relatando a conduta criminosa dos filhos e autorizando o ingresso dos policiais no imóvel, foi acostada às fls. 182/184.

Na fase policial e em Juízo o acusado Ramon atribuiu a propriedade da droga e do dinheiro ao corréu, responsável pela execução da traficância no imóvel.

O réu Francisco, em ambas as manifestações, admitiu a prática do comércio ilícito, todavia, negou a participação do irmão.

Francisca Regina Estevão da Silva, genitora dos denunciados, inconformada com a atitude dos filhos ao comercializar drogas no imóvel, compareceu na Delegacia de Polícia a fim de relatar os fatos, tendo anuído com o ingresso dos agentes na residência, onde encontraram a substância ilícita e o dinheiro.

Segundo policiais, após indicação da genitora, realizaram buscas na residência, localizando-se, nas vestes de ambos os réus, o dinheiro, além de, no lixo da cozinha, as porções do entorpecente.

Vale lembrar que o fato de policiais que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem os agentes incriminar os réus ou forjar os crimes. Neste sentido, importa registrar a seguinte decisão do Eg. Supremo Tribunal Federal: "o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

Urge consignar ser grande a quantidade de droga apreendida em comparação à condição financeira dos réus, que não comprovaram relação efetiva de emprego, logo, seria imprópria somente a eventual uso, sendo a venda ou guarda, medida impositiva no caso.

Como não se produziu prova a contrariar o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se que não há apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciar terem os acusados praticado o tráfico ilícito, com auxílio mútuo.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues). Ainda sobre o assunto: "Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado" (TJSP Ap. 187.915-3/2 Rel. CRISTIANO KUNTZ - RT 727/478). Por fim: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP "RT"729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito" (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

O que importa, no caso, é terem sido os entorpecentes localizados na posse dos réus, em situação de comercialização, o que acontecia com envolvimento de ambos, repita-se.

A análise conjunta das circunstâncias apresentadas leva à conclusão de terem os réus praticado os ilícitos em testilha, quais sejam, o tráfico de entorpecente e a associação para o tráfico de droga.

Não há dúvida no sentido de dividirem os réus as atribuições para que o tóxico fosse comercializado, ou seja, associados, os irmãos mantinham em depósito o

entorpecente, por ambos negociado.

Em outras palavras, exerciam os réus atividades essenciais para o comércio de entorpecente, havendo vínculo associativo entre eles, uma predisposição comum de meios para a venda de produto ilegal, especialmente ante o parentesco por eles mantido.

Além disso, a quantidade da droga apreendida e a forma de embalagem, somadas às circunstâncias acima analisadas, nos moldes do art. 239 do Cód. de Proc. Penal, levam à dedução de que seria por ambos posta em comércio, até porque, não contam os réus com situação financeira que os permita manter tal quantidade de droga para outro fim.

É possível que façam os réus uso do tóxico, mas a venda ou guarda é certa, até para garantir o uso. Além disso, a condição de usuário não afasta a de traficante.

Convencida da responsabilidade penal dos réus, passo a individualizar as penas.

- RAMON BARBOSA DA SILVA:

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06: Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

- art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06: Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em obediência ao caput do art. 69 do Cód. Penal, a pena totaliza 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa.

- FRANCISCO RÉGIS BARBOSA DA SILVA:

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06: Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Verificada a reincidência (fls. 79/90), incide a circunstância agravante contida no art. 61, inc. I, do Cód. Penal, que se compensa com a confissão da autoria, circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. III, "d", do mesmo Código, permanecendo inalterada a pena.

- art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06: Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Verificada a reincidência (fls. 79/90), incide a circunstância agravante contida no art. 61, inc. I, do Cód. Penal, razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Em obediência ao caput do art. 69 do Cód. Penal, a pena totaliza 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1.433 (mil quatrocentos e trinta e três) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão, para ambos os réus, é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.464/07).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, para ambos os réus, já se observou o período de prisão provisória, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. de Proc. Penal.

O fato de terem os réus respondido encarcerado à instrução do feito não implica, com a prolação desta sentença, na imposição de regime menos gravoso. Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTENTE - PLEITO DE DETRAÇÃO - REGIME INICIAL FIXADO ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM O ARTIGO 59 DO CP C/C ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS - RECURSO DESPROVIDO. 1 -

Caracteriza-se a omissão quando a Decisão silencia sobre ponto fundamental ou relevante. 2 - Não há omissão a ser sanada, na medida em que esta Colenda Câmara

enfrentou detidamente todas as questões levantadas no apelo interposto, tendo apreciado de forma suficiente a pretensão deduzida, embasando seu entendimento na jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3 - O regime inicial de

cumprimento da pena não levou em consideração o critério objetivo da pena, mas sim o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal c/c artigo 42 da Lei de Drogas. 4 - O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória em razão de haver outras circunstâncias que sustentam a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 5 - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00030386020128080047, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 01/10/2014, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2014).

Deixo de aplicar o § 4º do art. 33 da lei em tela, ante a quantidade de droga, a associação para o tráfico e a reincidência de Francisco, o que aponta maior periculosidade dos agentes, indicando integrarem organizações criminosas, mesmo porque, não existe comprovação de atividade laborativa.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da lei de Drogas quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 do mesmo diploma legal, por estar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, especialmente voltada, no caso, para o cometimento do narcotráfico" (REsp 1408701/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 19.11.2015).

O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica dos acusados (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno RAMON BARBOSA DA SILVA, R.G. n.º 49.534.448, a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, e FRANCISCO REGIS BARBOSA DA SILVA, R.G. n.º 71.086.567, a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.433 (mil quatrocentos e trinta e três) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por terem infringido os arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal.

Não poderão os réus apelar desta sentença em liberdade, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.464/07. Ainda que assim não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do feito, a prolação desta sentença condenatória, por graves delitos, apenas reforça os motivos ensejadores do afastamento dos réus do convívio social, por garantia da ordem pública.

Recomendem-se os réus no presídio onde se encontram, expedindo-se mandado de prisão, caso necessário.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflitivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação dos delinquentes.

Observados o art. 63 da Lei nº 11.343/06 e o art. 91, inc. II, "b", do Cód. Penal, DETERMINO O PERDIMENTO do dinheiro, porque obtido em razão do comércio ilícito de drogas, conforme prova colhida. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial a fim de serem destruídas as amostras de entorpecente guardadas para contraprova.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C..

São José do Rio Preto, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA